

1003373-42.2019.8.26.0071
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Liminar
Magistrado: José Renato da Silva Ribeiro
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública
Data de Disponibilização: 06/04/2022

... que na verdade nunca existiu tráfico de influência em razão função que anteriormente exercia como Carcereiro Policial; sendo que afinal da peça em comento requer a absolvição do processado por não existir no conjunto probatório qualquer prova que indique a suposta infração disciplinar. Em continuação aos trâmites do citado processo administrativo, em data de julho de 2017, o Dr. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
2ª Vara da Fazenda Pública
Rua José Ruiz Pelegrina, 6-60, Bauru - SP - cep 17018-620
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1003373-42.2019.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1003373-42.2019.8.26.0071
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Liminar
Requerente:
Sérgio Thanis Garrido
Requerido:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Renato da Silva Ribeiro

Vistos.

SÉRGIO THANIS GARRIDO, já qualificado, propôs ação anulatória de penalidade cassação aposentadoria em face da FESP. Aduz, em suma, que sofrera processo disciplinar apesar de já existir pedido de arquivamento por falta de provas. Ainda, diz que a defesa apresentou em data de 10 de agosto de 2015, suas alegações finais conforme mostra documentação em anexo. Quando na época o defensor do autor era o Dr. Carlos Alberto dos Rios, documento esse que relata que jamais existiu por parte do aposentado qualquer prática de irregularidade funcional; constou inclusive no item 32 das alegações finais, que a acusação interrogou os funcionários do DETRAN, os quais foram unânimes em afirmar que não conhecem o processado, esclarecendo que na verdade nunca existiu tráfico de influência em razão função que anteriormente exercia como Carcereiro Policial; sendo que afinal da peça em comento requer a absolvição do processado por não existir no conjunto probatório qualquer prova que indique a suposta infração disciplinar. Em continuação aos trâmites do citado processo administrativo, em data de julho de 2017, o Dr. Delegado Geral de Polícia Youssef Abou Chain, determinou o sobrestamento do processo disciplinar até final decisão do inquérito policial, com fulcro no art. 65, § 3º, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo,

em anexo, por ter entendido que não existia elementos suficientes que autorizassem o prosseguimento do citado procedimento, ou seja, até aquele momento as provas existentes no procedimento administrativo se mostravam frágeis e não possuía lastro probatório que pudesse amparar qualquer outro ato. De acordo como mostra em anexo o documento, datado de dezembro de 2018, muito embora durante todo o processado tenha restado claro que o autor não tenha participado de forma alguma de qualquer ato indisciplinar, em face de todas as provas coligidas aos autos, mormente por se encontrar encartado nesses autos o documento juntado, onde a certidão de objeto de pé referente ao Inquérito Policial, indique que até a presente data não houve qualquer denúncia de crime perpetrado pelo autor, o qual encontra-se em tramitação desde o ano de 2013, num total de 6 anos, o então Dr. Secretário da Segurança Pública, o qual não pertence mais a Secretaria da Segurança Pública, decidiu por cassar a aposentadoria do autor. O autor sendo citado para defesa, de acordo como mostra o documentação, apresentou em tempo hábil, sua defesa conforme mostra documentação em anexo , recurso esse dirigido ao excelentíssimo Secretário da Segurança Pública, de acordo com o art. 119, da Lei Orgânica da Polícia Civil, mais precisamente indicando os §§ 4º e 5º. Pede seja anulado o ato; ainda, pede a condenação por danos morais e mais os pagamentos que foram cancelados a título de aposentadoria. Juntou documentos.

Citação determinada, sem a concessão de tutela de urgência.

Contestação em fls. 131/140 , em que o réu nega o direito do autor. Alega que o autor cometeu fato relacionado a infração. Que deve prevalecer a decisão em sede administrativa.

Houve réplica.

Saneador em fls .296/297.

Audiência de instrução, debates e julgamento em fls. 326 e 331 .

Relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de pedido de anulação da decisão administrativa que, em sede de PAD, houve a aplicação de sanção de cassação de aposentadoria (do então servidor público do quadro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Busca o autor afastar os efeitos da decisão administrativa em sede de Processo Administrativo Disciplinar GS/9521/17 - DPH/0990/15.

O pedido não procede.

Inicialmente, cabe destacar que o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF n. 418, consolidou o entendimento no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário. Logo, para os casos em que pode haver demissão, na aposentadoria, poderá incidir a sanção de cassação de aposentadoria.

Mais do que consagrada a regra constitucional da Separação dos Poderes (CF, artigo 2º). Nas palavras acertadas do saudoso mestre Celso Ribeiro Bastos (Curso de Direito Constitucional, Malheiros, p. 227):

“Também se arrola entre os princípios fundamentais a chamada tripartição dos poderes, que poderia ter sido melhor chamada de tripartição de funções, uma vez que o poder ao povo pertence. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são meras funções desempenhadas pelo Estado, que exerce o poder em nome do povo. O traço importante da teoria elaborada por Montesquieu não foi o de identificar

estas três funções, pois elas já haviam sido abordadas por Aristóteles, mas o de demonstrar que tal divisão possibilitaria um maior controle do poder que se encontra nas mãos do Estado. A idéia de um sistema de "freios e contrapesos", em que cada órgão exerça as suas competências e também controle um do outro, é que garantiu o sucesso da teoria de Montesquieu.

Hoje, no entanto, a divisão rígida destas funções já está superada, pois, no Estado contemporâneo, cada um destes órgãos é obrigado a realizar atividades que tipicamente não seriam suas.

Ao contemplar tal princípio, o constituinte teve por objetivo - tirante as funções atípicas previstas pela própria Constituição - não permitir que um dos "poderes" se arrogue o direito de interferir nas competências alheias, portanto não permitindo, por exemplo, que o executivo passe a legislar e também a julgar ou que o legislativo, que tem por competência a produção normativa, aplique a lei ao caso concreto."

Bem. Os fatos jurídicos podem produzir efeitos em vários ramos do ordenamento jurídico, visto que este é uno. Um fato ilícito (espécie de fato jurídico) pode importar isoladamente a uma sede jurídica, como, por exemplo, o direito reparatório decorrente de acidente de trânsito em que nada seja abalado (nada de jurídico seja ofendido), a não ser a mera diminuição patrimonial decorrente do abalroamento do veículo automotor e dos dias em que vítima não pôde laborar.

Entretanto, se o motorista, no mesmo exemplo de acidente de trânsito, for agente público vinculado por regime de direito público (um motorista de ambulância de hospital público), o fato implicará na incidência de outras normas jurídicas, dentre tais as de Direito Administrativo, como infração disciplinar, se previsto em lei própria do ente público. Ainda, se o fato por previsto como elemento de fato jurídico criminal (fato típico), imporá a incidência de outras normas jurídicas, de específica natureza punitiva.

Ocorre a previsão do fato no ordenamento jurídico como elemento de fato ilícito em vários campos jurídicos. Por isso, não há proibição de autônomas consequências para o infrator, pois cada sede está sob o jugo da incidência de normas diferentes. É claro que a satisfação de resultados danosos num certo campo pode implicar efeito automático no outro, como a reparação civil. A lei pode implicar na obrigatória consideração, por exemplo, de pagamento de indenização para a vítima no processo criminal como começo, ou até sua integralidade, de indenização, visto que a finalidade da ordem jurídica é, também, no caso, de ressarcir civilmente a vítima, e, para tanto, não importa a sede.

O crime de homicídio doloso, por exemplo, se cometido por qualquer agente público, está afeto a inúmeras incidências normativas, implicando na responsabilidade civil, na de índole penal e na de índole administrativa, ainda que seja o 'melhor servidor público da história', como visto nos termos do artigo 92, inciso I, do CP. Não se trata de efeito automático. Porém, plausível dentro do mérito administrativo entender que um homicida não pode mais fazer parte do quadro funcional. Esta decisão é puramente administrativa. Interferir na escolha do superior hierárquico é interferir num dos Poderes da República.

É claro que o agente público não será demandado em sede de processo administrativo disciplinar se não obedecidos os requisitos legais e serem-lhe permitidas todas as armas previstas na Constituição Federal. Apenas se (e na maioria das vezes está) prevista a penalidade em lei do ente político e nos termos da lei, sem olvidar de direito de defesa, de produção de provas, dentre tais a impossibilidade de meios de prova que ofendam, materialmente, a Constituição Federal, provas estas ilícitas, além de que estejam dentro daquelas previstas para o rito (ilegítimas).

Ora, as normas que se referem à obrigatória comunicabilidade da decisão criminal -

comunicabilidade de instâncias – são, notadamente, o artigo 935 do Código Civil e o artigo 65 do Código de Processo Penal. Por tais normas entende-se que aquilo que condena (procedência) no juízo criminal repercute na esfera cível, ou seja, também condena, não havendo mais discussão acerca da existência do fato danoso e de quem o cometeu. São esferas autônomas, nos termos da lei, mas aquilo que fora julgado com maior amplitude de garantias constitucionais ao réu criminal (ofensor-devedor) repercute na esfera civil (responsabilidade civil).

Outras regras podem ou não ser aplicadas na comunicabilidade da sentença penal que absolve (CPP/386). Isto porque depende do fundamento em que a sentença criminal absolver o réu. O artigo 935 do CC aplica-se em conjugação com o inciso I, do artigo 386 do CPP. Assim a doutrina de DI PIETRO (Direito Administrativo, 31ª edição, p. 788):

“a) repercute na esfera administrativa a absolvição:

- (i) por estar provada a inexistência do fato (art. 386, I, do CP, e 935 do CC);
- (ii) por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CP, e 935 do CC);
- (iii) por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (artigo 65 do CPP);

b) não repercutem na esfera administrativa:

- (i) absolvição com base no art. 386, III, do CPP (o fato não constitui crime);
- (ii) as hipóteses de absolvição por falta de prova (art. 386, II, V e VIII, do CPP).

c) fato que constitui crime, mas não constitui infração administrativa: Súmula 18 do STF: “pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do serviço público”.

d) efeitos da condenação criminal: perda do cargo, função pública ou mandato em duas hipóteses: 1ª) quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 2ª) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, nos demais casos; o efeito não é automático, pois depende de declaração do juiz na sentença (art. 92 do CP, com a redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º-4-96).”

Obviamente que a punição encontra balizas naquilo que o ordenamento jurídico prevê como reflexo da sentença penal absolutória, mas, como visto acima, apenas nas estritas hipóteses previstas. O fundamento para a absolvição não faz coisa julgada no juízo cível quanto aos pontos de fato que levaram à absolvição.

Muito embora o dispositivo na sentença penal vincule-se às categorias jurídicas da fundamentação, diversamente do que se passa para a sentença cível de improcedência (meramente declaratória), a sentença penal absolutória – assim como qualquer outra sentença – não se vincula aos meros pontos de fato que tomou conhecimento o juiz e entendeu que não havia de prova suficiente para a condenação (inciso VII, do artigo 386 do CPP). A coisa julgada material não se estabelece para alcançar meros fatos – mero fundamento – ligados à prova.

Essas questões de mérito – autônomas a ponto de necessitarem de ação cível a ser movida pelo réu – serão obrigatórias no juízo criminal, visto que cabe ao juízo cível decidir sobre a elementar penal, o que implicaria na absolvição do réu. Caso não julgue o juízo cível procedente o pedido, o juízo criminal poderá absolver ou condenar.

Com efeito, o que o ordenamento jurídico confere como importante é, exclusivamente, a consideração de certas questões de mérito, que teriam então influência na sentença de outro juízo, nunca mero fato ou argumento fático para a absolvição (e isto se passa para qualquer sentença, cível ou criminal). Percebe-se que, em casos excepcionais, quando houver prejudicial de mérito, questão de direito tratada de modo especialíssimo pelo direito processual, haverá vinculação do juízo penal.

POIS BEM.

O autor fora processado em sede de Processo Administrativo Disciplinar n. GS/9521/17 – DPH/0990/15 (fls. 19 e seguintes), para o fim de aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Os fatos que implicaram na instauração do Processo Administrativo foram graves e ensejadores, a princípio, de punição disciplinar.

Há documentação (como caderno em poder de terceiro que aponta o autoa como partícipe, que teria realizado procedimentos de baixa de bloqueio dos veículo sinistrados adquiridos pela quadrilha então objeto de investigação no Estado, gerando benefício de terceiros – fls. 21 e 22) e depoimentos em sede de processo administrativo disciplinar.

Não há vício algum no PAD. O autor não aponta qualquer desvio no processo administrativo em tela. Realmente, em fls. 23, há confissão do autor, à época, de ter protocolado. A intenção de vantagem pessoal não é elementar do fato típico. A mera circunstância de atuar perante órgão público – DETRAN –, tendo em conta favorecimento de terceiro, ainda que o agente não receba dinheiro ou vantagem de estilo material, não importa ao fato típico criminal.

No mais, as testemunhas da Administração, ouvidas a partir de fls. 23, deitaram considerações sobre a investigação da quadrilha, que receptava veículos subtraídos na Região de Piracicaba, transplantavam peças em veículos adquiridos ilegalmente em leilões. Há conexão entre o achado em livreta de anotação de terceiro e a ação do autor, então processado, o que implica numa maior sobreposição com a veracidade dos fatos. Isto é, não fora nada alheio ou com a fina camada duma confissão de terceiro que tenta incriminar o autor.

Carlos (fls. 24) trouxe informações que confirmaram conhecimento de que o autor era policial civil e tinha o autor, dentre outros, facilidade para contatos com pessoas em SP. Ainda: que o autor prestava serviços a despachantes policiais. Em fls. 25 e seguintes, houve oitiva de despachantes, que confirmam que o ora autor atuava em serviço dos despachantes.

Enfim, em fls. 30, há, diante da conclusão pelo ganho probatório, entendimento de que o autor, ex-carcereiro aposentado, infringiu o disposto no artigo 62, inciso II e IX, artigo 63, incisos X, II e XXVII e artigo 74 inciso II, todos da Lei Complementar Estadual n. 207/1979 (alt. LCE 622/2002), opinando a autoridade pela pena de cassação de aposentadoria. Houve opiniões de outros delegados. Houve também o Parecer 123/2017 (fls. 61 e seguintes; fls. 71, em que concorda com pena de suspensão). Houve, contudo, prevalência da Decisão em sede de Assessoria Disciplinar (fls. 75 e seguintes; v. fls. 79), perfeitamente cabível.

Vale asseverar que, em casos como o dos autos, repita-se, o Poder Judiciário não é vistor ou revisor da esfera administrativa. Não há como o presente juízo reavaliar a prova produzida e o nexos com a decisão administrativa punitiva, pois inexistente revisão judicial de mérito administrativo. O Poder Judiciário analisa legalidade, não ocorrendo nada de desvinculação com maciça prova em sede de processo administrativo, ao qual o autor tivera amplíssimo acesso. Se o autoridade administrativa houvesse fundado demissão ou cassação em uma ou outra testemunha, poder-se-ia dizer que nada teria sido concludente.

Mas, não, pela documentação acostada, há prova de que o autor participou de ações criminosas. Até mesmo quando houve opinião para outras sanções administrativas, tais não deixaram de lograr encontro nas amplas provas contra o autor. O que houve fora a escolha da autoridade maior antes do Governador do Estado, pela causalidade com a demissão ou cassação. A falta de adequação está no limbo com o mérito administrativo e a legalidade. No caso concreto, nada de extraordinariamente inadequado para entender que não houve fatos relacionados à cassação (ato ilícito que importaria demissão). Se a autoridade entendeu que os fatos bem provados deram ensejo à demissão, não cabe ao Poder Judiciário rever.

O Poder Judiciário apenas pode verificar se os autos administrativos continham elementos de prova suficientes para a decisão punitiva, pois tal compreende em análise jurídica do PAD, ou seja, que não se tratou de demissão baseada em mera prova indiciária, como a petição inicial acusa.

Com efeito, a d. Decisão, aplicando penalidade administrativa, não apresenta vício de legalidade, até mesmo porque, para fundar as ações infracionais do autor, verificou-se que os fatos que seriam passíveis de demissão.

Repise-se. A penalidade administrativa é esfera autônoma de qualquer sorte em processo criminal. Algumas penalidades administrativas estão, obviamente, espelhadas no fato criminal. Mas sequer a investigação criminal tem efeito na esfera administrativa. Caso não haja processo criminal, ou sequer inquérito, ou requerimento de arquivamento, não há ultraeficácia destas decisões interlocutórias criminais.

Com efeito (como na doutrina suscitada), hipótese em que há ação judicial, com amplo contraditório, repercute na esfera administrativa a absolvição: por estar provada a inexistência do fato (art. 386, I, do CP, e 935 do CC); por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CP, e 935 do CC); por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (artigo 65 do CPP).

Já não repercutem na esfera administrativa: absolvição com base no art. 386, III, do CPP (o fato não constitui crime); as hipóteses de absolvição por falta de prova (art. 386, II, V e VIII, do CPP). Fato que constitui crime, mas não constitui infração administrativa: Súmula 18 do STF: “pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do serviço público”. Os fatos podem, diante das garantias constitucionais ao cidadão de não perseguição, pelos prazos e outros elementos que cabem ao Ministério Público análise e conveniência, mas não atingem a esfera punitiva da administração pública.

Eventual perseguição, tão perfunctoriamente versada pela testemunhas, não é prova cabal de qualquer fato que não teria ocorrido tal como descrito e provado no PAD em tela. Vale insistir que as testemunhas não falaram qualquer palavra relevante sobre os fatos que deram fundamento à decisão administrativa demissional. As testemunhas, delegados e funcionários que trabalharam com o autor, não versaram sobre os fatos estruturais do PAD. Aliás, o autor não nega que atuou e as testemunhas não desmentem qualquer circunstância fática utilizada no fundamento da cassação.

Por fim, repita-se à exaustão, não houve qualquer mácula de ilegalidade aos autos administrativos. Não cabe ao Poder Judiciário rever mérito administrativo, qualquer que seja, desde uma placa de trânsito num lugar aparentemente sem sentido, ou numa faixa amarela sem muita necessidade, como casos graves como o dos autos, em que a autoridade administrativa competente decidiu, em sede ampla de prova e de respeito aos princípios constitucionais, na pena igualmente grave de cassação de aposentadoria.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto por SÉRGIO THANIS GARRIDO, já qualificado, já qualificado, em face da FESP. Extingo o feito com fulcro no Artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbência pelo autor, diante do que o condeno em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa. Observe-se a gratuidade da justiça deferida.

P. R. I.

Bauru, 6 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA